

I sistemi di ordine negoziato in Oriente e nell'Occidente europeo

Avv. Carlo Alberto Calcagno

L'arduo compito di questa nota è quello di dare un breve sguardo a come i meccanismi negoziali di composizione dei conflitti hanno interagito con la **Storia** e a come si pongono nel **mondo odierno**.

Preliminarmente mi importa illustrare separatamente il punto di vista di un uomo orientale rispetto a quello di un occidentale dinanzi al conflitto, poiché i sistemi di composizione si qualificano in primo luogo in relazione al differente modo di affrontarlo.

Si racconta che un famoso poeta¹ di Haikai assegnasse ad un suo discepolo il compito di comporre una lirica su di un peperoncino rosso.

Il testo che ne venne fuori fu il seguente: *"Se ad una libellula rossa strappassi le ali otterrei un peperoncino rosso"*. Il maestro corresse prontamente lo studente: *"Se ad un peperoncino rosso aggiungessi le ali otterrei una libellula rossa"*.

Al di là dell'insegnamento sulla **non violenza** così caro all'uomo orientale possiamo cogliere qui anche un altro elemento peculiare della sua mentalità: l'armonia è frutto dell'aggiunta, dall'unione degli elementi e non dalla loro sottrazione o divisione.

Questo insegnamento si traduce in un **principio fondamentale** che anche noi occidentali stiamo iniziando ad intuire come **l'essenza della mediazione**: la soddisfazione di coloro che negoziano può essere raggiunta soltanto se **si amplia** la base negoziale e non quando si riduce.

La qualcosa, ci insegnano, i popoli orientali si può raggiungere anche con una reciproca **rinuncia**: dal che si potrebbe dedurre che gli Orientali guardino alla **mediazione** come noi guardiamo alla **transazione**².

Ma la **finalità** di questo strumento nei due sistemi è assai differente.

I Paesi dell'Asia orientale che sono influenzati dalla **filosofia confuciana**³, possiedono una cultura della conciliazione per cui gli strumenti di ordine negoziato sono da tempo un **meccanismo preferenziale** per la risoluzione di una controversia.

¹ Matsuo Bashō (1644-1694).

² Art. 1965 del Codice Civile: *"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*.

Questa cultura è in netto contrasto con il **contraddittorio occidentale**, uno strumento basato sulla individualità, che considera i conflitti e le dispute secondo diritto⁴.

In altre parole in Oriente di fronte al conflitto gli uomini hanno da millenni **una mentalità conciliativa** e non cercano di affermare il loro **diritto**: di fronte ad una controversia si pongono *in primis* queste domande: “*In che cosa ho sbagliato?*”, “*quale era il mio dovere*”?⁵

Sono convinti in poche parole che per condurre **una vita perfetta**, in armonia, è necessario compiere bene il proprio dovere⁶ e non sconfiggere gli altri.

E ciò perché per l'uomo giapponese è **condizione naturale** fare ogni cosa in gruppo, sentirsi sotto lo sguardo attento di altri che lo considerano **prezioso e desiderabile**.

E dunque vivere deliberatamente per minimizzare **l'interferenza** dei propri malintesi, illusioni e sofferenze irrisolte.

Se prendiamo ad esempio il modello di **mediazione giapponese**⁷ vediamo che esso si basa, sulla ricerca dell'**armonia sociale**, sull'**adempimento morale**, e su altre considerazioni **extra-giuridiche**.

I Giapponesi amano l'impegno sociale come strumento di connessione, ma nello stesso tempo la cultura spinge ad uniformarsi ad **un gruppo ristretto**.

Hanno un concetto di **società verticale**, detto *Tate Shakai*⁸ che permea tutte le interazioni tra gli individui, e determina le posizione di ogni individuo rispetto agli altri, sulla base di età, sesso, istruzione, e professione⁹.

³ Confucio è un filosofo cinese che operò tra il 551 ed il 479 a. C. ed i suoi insegnamenti influenzarono la vita cinese, coreana, giapponese e vietnamita.

⁴ Y. SATO, *Commercial Dispute Processing and Japan*, in New York: Kluwer Law International, 2001, p. 330.

⁵ G. COSI, *Perché conciliare?* in dispensa Corso Base e di specializzazione per conciliatori ai sensi del d.lgs. n. 5/03, Associazione Equilibrio & Risoluzione delle controversie, 2010.

⁶ Non a caso i samurai seguivano un codice d'onore detto Bushido alla cui base stanno i seguenti principi:

“Gi” la decisione giusta, la risolutezza, la corretta strada da percorrere;

“Rei” il comportamento di gentilezza e cortesia anche verso i propri nemici;

“Yu” l'abilità, sia tecnica sia umana, che si esprime nel coraggio;

“Meido” l'onore e la gloria sul campo di battaglia e nella vita;

“Jin” l'amore universale, la benevolenza verso tutte le persone;

“Makoto” la sincerità totale, in ogni occasione della vita;

“Chu” la devozione e la lealtà verso il proprio padrone e i propri compagni.

Cfr. *amplius* G. LUCARELLI, *Manager, samurai e “l'Arte della spada”*. *Saggezza antica per problemi moderni*. 9 Settembre 2011. In <http://www.ticonzero.info/articolo/manager-samurai-e-l-arte-della-spada-saggezza-antica-per-problemi-moderni/2081/>

⁷ In materia lo scritto più importante in materia di sistemi di composizione dei conflitti in Giappone risulta ancora oggi il seguente: T. KAWASHIMA, “*Dispute Resolution in Contemporary Japan*,” in Arthur Taylor von Mehren, ed., *Law in Japan: The Legal Order in a Changing Society* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963).

Della propria collocazione bisogna essere **degni ed appagati**. Dunque è considerato un vero e proprio **fallimento** dover ammettere un **errore** ed essere redarguiti dalla **struttura sociale** di riferimento: i Giapponesi non amano quindi il processo e le procedure avversariali perché esse sono strutturate necessariamente per attribuire **ragioni e torti** e appartengono quindi ad una cultura della **colpa** che non conoscono.

Essi vivono, infatti, **una cultura della vergogna** (*shame culture*) come facevano gli eroi omerici, seppure per motivi e con esiti differenti¹⁰.

Si dice che sussiste una cultura della vergogna laddove l'osservanza delle regole **non è ottenuta attraverso divieti**¹¹, ma attraverso modelli positivi di comportamento: chi non si adegua a questi modelli incorre nel **biasimo sociale** ed in una sensazione di **inadeguatezza** definita appunto "vergogna".

Conseguentemente i Giapponesi pensano di essere eguali agli altri nel momento in cui **evitano la lite**, non quando la fomentano¹².

Il contenzioso è considerato, in altre parole, **offensivo** per coloro che vogliono mantenere in piedi il sistema vigente di sottomissione gerarchica alle autorità.

D'altro canto essi sono mossi anche dai principi di **compassione e benevolenza**.

Per i Giapponesi del resto la stessa **salute mentale** dipende dall'**interdipendenza**. E per interdipendenza intendono uno stato esistenziale in cui **si ricevono cure ed attenzioni dagli altri e si ricambiano**.

In questa prospettiva la malattia mentale è vista come una **disconnessione** dagli altri ed **un ritiro nell'egoismo**¹³.

⁸ Il termine è stato coniato da un'antropologa sociale giapponese di nome Chie Nakane (cfr. C. NAKANE, *La società giapponese. "L'estraneità comincia dal fratello"*, Traduzione: Francesco Montessoro - Nicoletta Spadavecchia, Raffaello Cortina, 1992. Titolo originale C. NAKANE, *Japanese Society*, University of California Press, 1970).

⁹ K. FUNKEN, *Comparative Dispute Management "Court-connected Mediation in Japan and Germany"*, (March 2001). University of Queensland School of Law Working Paper No. 867. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=293495> or doi: 10.2139/ssrn.293495.

¹⁰ L'eroe omerico quando non riusciva ad adeguarsi al modello che gli imponeva di "eccellere sempre" attribuiva la responsabilità a forze esterne, alle divinità e così con un *transfert* evitavano la sensazione psichica. Cfr. E. CANTARELLA, *Diritto greco*, Cuem, Milano, 1994, p. 25 e. ss

¹¹ In questo caso si parla di cultura della colpa.

¹² V. G. FINOCCHIARO, in Guida al Diritto, n. 12 del 20 marzo 2010, *Il Sole-24Ore*, p. 55. Così erano anche i Romani dell'età arcaica (754 - III sec. A. C.) la cui personalità risultava assorbita nell'ambito della famiglia in cui vivevano (v. A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, UTET, Torino, 1987, p. 11).

Non stupisce dunque che **i diritti legislativamente previsti** non siano necessariamente riconosciuti dalla loro procedura non avversariale: i mediatori **non sono cioè vincolati dal diritto** o dal peso delle prove ufficiali¹⁴.

Il loro negoziato si fa guidare più dalla ragione, dal senso comune, dall'equità e dall'etica. Ciò li ha aiutati a guardare per millenni al proprio approccio **alla questione** e non alla persona dell'altro.

Questa è l'ottica che ha permesso loro di **non considerare l'altro come un nemico**, ma come un avversario che ha punti di vista **differenti**, un avversario con cui si può e si deve cercare una soluzione.

Dalla soluzione alla questione dipende, infatti, **la crescita personale**: attraverso l'altro si può mettere alla prova e valutare quelle che sono le proprie possibilità, capacità ed individuare quelli che sono i propri limiti.

Se si desidera, al contrario, annientare l'altro (considerandolo un nemico) si annienta in primo luogo **la propria persona e la possibilità di crescita**.

Per questi motivi sino alla fine dell'Ottocento in Giappone si ignorava addirittura il processo¹⁵, gli avvocati erano **pochissimi** e pure nel Novecento nonostante i cambiamenti sociali il tasso di litigiosità **non è aumentato**: e ciò sostanzialmente perché il Giapponese nutre deferenza per l'Autorità e al culto per l'armonia, ma anche perché il contenzioso richiede **tempo e denaro** ed anche avendo denaro e tempo a disposizione i risultati del contenzioso costituiscono una **compensazione minima**¹⁶.

La tradizione di mezzi non avversariali di risoluzione delle dispute è perciò plurisecolare ed ancora oggi che il paese è di *civil law*, gli strumenti di ADR hanno la prevalente diffusione.

E ciò perché, lo ribadiamo, la risoluzione delle controversie in Giappone richiede **il ripristino dell'armonia e la comprensione reciproca**. La composizione armoniosa delle

¹³ L. COZOLINO, *Il Cervello Sociale. Neuroscienze delle relazioni umane*, Raffaello Cortina Edizioni, 2008, p. 339 e ss. Al contrario, secondo l'autore, l'individualismo radicale occidentale è uno dei motivi per cui abbiamo tanti disturbi psicologici, dipendenza dalla droga e dalla violenza.

¹⁴ E questa è anche una connotazione della nostra mediazione, seppure in misura minore.

¹⁵ Il concetto venne introdotto ivi dagli Occidentali.

¹⁶ Cfr. E. FELDMAN, *Law, Culture, and Conflict: Dispute Resolution in Postwar Japan*, 13 settembre 2007, p. 54 e ss. in NELLCO Legal Scholarship Repository, University of Pennsylvania Law School. <http://lsr.nellco.org>

controversie attraverso la mutua comprensione è virtuosa, la lotta giudiziale è vergognosa¹⁷.

Ultimamente si sta pensando ad una riforma della giustizia per valorizzare il contezioso giudiziario, ma alcuni partiti, al contrario, vorrebbero affidare un ruolo più ampio ai **metodi di risoluzione alternativi delle controversie**¹⁸.

I metodi di risoluzione alternativa delle dispute (*Alternative Dispute Resolution*) in Giappone comprendono l'arbitrato, la mediazione, la conciliazione e, in generale, la negoziazione, per quanto in questo paese sia **improprio** per le ragioni che precedono parlare di alternatività.

Per la verità anche in Occidente oggi il termine “*alternative*” sta per “adeguato” al caso concreto.

Gli organismi di ADR si possono trovare nelle corti giapponesi, ma possono anche essere organizzazioni private.

La legge sulla promozione dell'uso della risoluzione alternativa delle controversie (The ADR act) è stata emanata nel 2004 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2007¹⁹.

Questa legge mira ad assicurare che i meccanismi di ADR siano equi ed efficaci, limitando il numero degli organismi a quelli che sono autorizzati dal governo²⁰.

I principali metodi utilizzati in Giappone sono comunque **l'arbitrato** (“*chūsai*”), e la **mediazione collegata al giudizio** (“*chōtei*”).

Il termine “Chotei” indicava un tempio la **Corte imperiale** dove l'imperatore governava, ma anche la stanza fisica ove si svolgeva tale compito ed in oggi il tribunale, una sala pubblica ove si tengono le udienze; la parola richiama dunque il concetto di *setting* tanto caro alla mediazione, ma anche alle discipline psicoterapiche.

La *chōtei* è il metodo “alternativo” più popolare ed efficace in Giappone: in media, un caso civile su tre va in chotei e c'è una media di risoluzione del 55%.

¹⁷ Cfr. FELDMAN, *Law, Culture, and Conflict: Dispute Resolution in Postwar Japan*, op. cit. p. 59.

¹⁸ Cfr. FELDMAN, *Law, Culture, and Conflict: Dispute Resolution in Postwar Japan*, op. cit. p. 72.

¹⁹ The Act on Promotion of Use of Alternative Dispute Resolution (Act No. 151 of 2004).

²⁰ “Lo scopo della legge sulla promozione dell'uso della risoluzione alternativa delle controversie è quello di fornire i concetti di base della legge e in riferimento alle responsabilità del governo e altri soggetti, e ad istituire un sistema di certificazione e di norme speciali in materia annullamento di prescrizione e di altre questioni in modo da rendere le procedure alternative di risoluzione delle controversie più facili da utilizzare, consentendo alle parti di una controversia di scegliere il metodo più adatto per risolvere una disputa con l'obiettivo di un'adeguata attuazione dei diritti e degli interessi del popolo” (Art. 1).

Si tratta di un procedimento precontenzioso (*court-connected mediation*) assai **economico**²¹ che si basa su un accordo tra le parti, fondato su **concessioni reciproche**²², condotto sotto la direzione di una *summary court*²³ o di una *district court* ovvero dalla sezione famiglia del *district court*²⁴.

In materia civile la *chōtei* è **volontaria**, tranne che per le **locazioni** e la famiglia. Viene usata di rado per le controversie commerciali.

Può essere disposta anche dal **giudice** solo all'inizio del giudizio²⁵, successivamente abbisogna del consenso delle parti.

Il giudice, sulla richiesta delle parti, nomina una **commissione di mediazione**²⁶ con un giudice togato che funge da presidente e due **non giudici**: sono circa 12.000 dipendenti pubblici **a tempo determinato** che possono essere riconfermati nel ruolo di mediatore (*chōteisha*); hanno tra i 40 e i 70 anni e **non sono necessariamente giuristi** (solo il 10%): sono **donne e uomini** se nominati dalla *Supreme Court* (la nostra Cassazione) per una questione di famiglia, più che altro **uomini** se nominati nel settore civile.

L'esperienza ha dimostrato che perché la *chōtei* funzioni è necessario che i mediatori provengano da svariati ambiti professionali e dai diversi livelli della società.

Nelle fasi iniziali dell'istituto molti mediatori erano scelti tra gli **anziani**, sostanzialmente maschi, che si distinguevano nella loro comunità.

Questi uomini avevano la tendenza ad insistere **sulle regole della comunità e sui valori tradizionali** che erano spesso contrari alla **legalità**, piuttosto che ad aiutare i contendenti ad aprire il negoziato.

A questo inconveniente si è ovviato appunto con la nomina di mediatori provenienti da diverse estrazioni sociali.

L'incontro di mediazione si tiene, come accennato, in luogo riservato del **palazzo di giustizia**: tuttavia, a differenza che nella mediazione "occidentale", i terzi che siano

²¹ Nel 2001 costava tra i 1000 e i 6000 yen ossia tra i 9 e i 54, 61 euro

²² Quindi non tanto sulla soddisfazione degli interessi come nella mediazione di Harvard.

²³ Una magistratura simile al nostro giudice di pace che ha competenza civile per le piccole cause, ma ha anche una competenza in materia di diritto di famiglia.

²⁴ Ossia il nostro tribunale.

²⁵ In tal caso prescinde dal consenso delle parti.

²⁶ Che ha tutti i poteri istruttori del nostro giudice civile.

interessati alla mediazione possono essere invitati a presenziare **d'ufficio** dalla Commissione.

La partecipazione personale è **obbligatoria** per tutti, a meno che non ci si avvalga di rappresentanti legali; se non ci si presenta ingiustificatamente si può essere condannati a pagare una multa di 50.000 yen (455 euro).

La procedura si stempera attraverso una prima sessione introduttiva nella quale si spiega la procedura alle parti ed in tutta una serie di sessioni private successive.

Non si svolgono sessioni congiunte per evitare che gli **sfoghi** delle parti possano ledere il **prestigio della commissione**: in questo senso la mediazione non può considerarsi una “negoziazione assistita” come da noi.

La commissione può fare delle **proposte concrete** ed incoraggiare le reciproche concessioni tra le parti²⁷.

I Giapponesi sono, infatti, in un certo senso **mentalmente predisposti** ad accontentarsi di **qualche cosa di meno** di quello che potrebbero ottenere attraverso il giudizio.

La procedura può durare **alcuni mesi**, così come può interrompersi in qualunque momento perché la commissione può dichiararla inappropriata al caso in esame ovvero può considerare l'accordo raggiunto come **irragionevole o sconveniente**.

Se le parti si conciliano e l'accordo invece **non è contrario** all'ordine pubblico o alla legge esso viene formalizzato e registrato dalla Corte²⁸.

Se le parti non si accordano o la mediazione fallisce la Corte può di sua iniziativa formulare **un ordine di determinazione in sostituzione dell'accordo di mediazione** che però deve tenere conto del parere della Commissione e delle proposte fatte dalle parti²⁹.

In Giappone esistono poi la procedura di divorzio mediato (“*chotei rikon*”).

La *chotei rikon* ha un ambito assai vasto e riguarda l'invalidità del matrimonio, la nullità del matrimonio, l'invalidità e la cancellazione del divorzio, il riconoscimento degli stati di vita o di morte in relazione al matrimonio, l'annullamento e la nullità dell'adozione, le dispute riguardanti la presenza o l'assenza dei genitori nelle relazioni con i figli, la

²⁷ Più che facilitatore della comunicazione il mediatore è qui un conciliatore tipo il nostro del 1865.

²⁸ Si definisce *chosho* ed ha valore di sentenza.

²⁹ V. *amplius* K. FUNKEN, *Comparative Dispute Management "Court-connected Mediation in Japan and Germany"*, (March 2001) cit.

divisione delle spese del matrimonio, i diritti parentali e la cura dei bambini al momento del divorzio (compresi gli alimenti), la divisione della proprietà al momento del divorzio, la determinazione dei diritti dei genitori al momento del divorzio, la modifica dei diritti dei genitori.

In **Cina** il primo caso di mediazione che i libri storici ricordino risale a circa 4000 anni prima di Cristo.

Si narra che il re **Sheun** riuscì a conciliare i membri di alcune comunità del suo regno che erano in contesa tra di loro per la proprietà di fondi e per la vendita di una partita di ceramiche³⁰.

Dell'utilizzo frequente della mediazione abbiamo poi soprattutto traccia nella **Cina occidentale** sotto la dinastia Zhou (1146-771 a.C.) e successivamente a livello nazionale durante la dinastia Qin (221 - 207 a.C.)³¹.

Si racconta poi che tra il 206 ed il 24 a.C. un funzionario di nome Wu Han, chiamato a dirimere le controversie, riflettesse sulle proprie responsabilità nei litigi altrui **e girasse per le case e per le strade** della sua contea per riconciliare i litiganti³²: comportamento quest'ultimo simile a quello che verrà tenuto quasi duemila anni dopo dal conciliatore del Regno delle Due Sicilie.

Nel terzo secolo a.C. furono introdotte in Cina le leggi scritte, ma sotto l'impero di tutte le dinastie sino all'ultima, la Qing (1911) ci fu sempre **un forte pregiudizio** verso il processo ed il diritto³³.

I Cinesi (ma anche i Coreani), considerano da sempre la regolazione dei rapporti umani attraverso la norma giuridica come un sistema **rudimentale** da utilizzarsi solo nei casi estremi (diritto penale).

Essi non hanno mai avuto in animo di risolvere i contrasti, ma di **dissolverli** ed hanno sempre ritenuto che l'astrattezza della norma giuridica non possa aiutare in tale compito,

³⁰ P. CAO, *The origins of mediation in traditional China*, in *Dispute Resolution Journal*, May 1999.

³¹ L. MEALEY-LOHMANN, *Using mediation to resolve disputes – Differences between China and the United States*, in <http://www.chinainsight.info>, 2010.

³² P. CAO, *The origins of mediation in traditional China*, op. cit.

³³ L. MEALEY-LOHMANN, *Using mediation to resolve disputes*, op. cit.

ma al contrario **impedisca la ragionevolezza degli accomodamenti**, se non costituisca addirittura fonte di **disordine sociale**³⁴.

In tale credenza i Cinesi assomigliano in qualche modo agli antichi Romani che avevano in origine un **diritto consuetudinario** e sino al Dominato³⁵ rifuggirono da una produzione di norme generali ed astratte, perché ritenevano che un'applicazione meccanica potesse risultare iniqua nei casi concreti³⁶.

Le leggi in Cina sono solo dei **modelli discorsivi** a cui avvicinarsi; gli stessi contratti vengono redatti in termini evasivi perché non servono a prevenire i contrasti futuri, ma a dare voce all'intesa delle parti³⁷.

In questo immenso paese la necessità della mediazione dipese **dall'organizzazione sociale**: nei villaggi non erano diffusi né l'industria né il commercio; la popolazione era formata per la stragrande parte da **contadini ed artigiani** che erano per lo più **parenti** tra di loro.

Di tale organizzazione tennero conto naturalmente anche i precetti filosofici: Confucio insegnava che il giovane doveva rispetto e obbedienza agli anziani e che tutte le persone che componevano il clan familiare **dovevano amarsi ed aiutarsi a vicenda**.

Durante la dinastia Ming³⁸ ogni villaggio era tenuto a costruire un padiglione denominato "shenming" ove i vecchi locali e la gente più colta risolvevano come giudici le controversie della gente del luogo, e nella maggior parte dei casi **intercedevano per una soluzione pacifica**.

A seguito di questi procedimenti sono nati alcuni precetti la cui osservanza tra le comunità locali è giunta sino ad oggi.

Le dispute andavano sottoposte in primo luogo al **capo clan familiare** che le risolveva secondo le regole di quella data comunità.

Il rispetto verso il sentimento dei clan familiari e di parentela era fondamentale e **trascendeva ogni ragione di debito e credito**, di torto o ragione; in altre parole il

³⁴ G. COSÌ, *Perché conciliare?* Op. cit.

³⁵ 235-565 d. C.

³⁶ V. A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, op. cit., p. 8.

³⁷ V. G. COSÌ, *Perché conciliare?*, op. cit.

³⁸ 1368-1644 d. C.

sentimento dei parenti e del clan patriarcale era molto più importante **degli interessi del singolo**.

Le regole etiche del clan erano e sono ancora oggi superiori anche alle leggi.

In particolare secondo l'etica del clan patriarcale i ricchi devono aiutare i poveri, e i forti devono sostenere i deboli.

Colui che rinunciava consapevolmente ai propri interessi per porre fine alle controversie con i suoi parenti era **molto apprezzato** dall'opinione pubblica, mentre colui che si rifiutava di aiutare i suoi parenti più deboli era oggetto di **critica** perché dimenticava la giustizia.

L'ordine sociale ideale era considerato quello dell'armonia e dell'assenza di contenzioso.

Per Confucio il compito più rilevante per un governante era quello di **insegnare al popolo a vivere appunto senza contenzioso**.

Coloro che ricorrevano al contenzioso venivano considerati **volgari ed immorali** e si riteneva che **non avessero mantenuto alta** la reputazione della famiglia, perché il compito della famiglia era appunto quello di istruirli a non coltivare contenziosi.

Gli stessi funzionari sin dall'antichità, in presenza di queste regole, erano assai cauti nell'intervenire nelle controversie, anche quando richiesti, e consideravano che sottolineare il torto o la ragione **potesse comportare soltanto inimicizia tra i parenti**; non era poi tanto importante punire chi violasse le regole familiari, ma fare in modo che comprendesse i suoi torti e cambiasse modo di vivere.

Oggi, con lo sviluppo dell'economia di mercato e la modernizzazione del sistema giuridico, la percentuale delle mediazioni **si è notevolmente ridotta**, ma la procedura è ancora ampiamente praticata per tre motivi: perché la legislazione è **incompleta**, vi sono **carenze** logiche ed assenza di dettaglio, le disposizioni legali sono **vaghe** e difficili da interpretare; in secondo luogo le sentenze sono **difficilmente eseguibili** a causa di vincoli finanziari, ed in ultimo perché la mediazione consente di mantenere un buon rapporto d'affari tra i due litiganti, mentre la sentenza emessa da un giudice può tradursi in una rottura nelle relazioni umane e commerciali³⁹.

³⁹ P. CAO, *The origins of mediation in traditional China*, in *Dispute Resolution Journal*, May 1999.

Nel particolare si può aggiungere che a partire dalla nascita della repubblica Popolare di Cina (1949) sino al 1980 la mediazione è **tornata ad essere il sistema più usato** per la composizione dei conflitti perché si diceva che le Corti dovevano adottare metodi democratici.

Dal 1980 al 2000 vi è stata invece una certa flessione, dovuta al fatto che si è maggiormente consolidato **l'utilizzo nel processo civile di regole generali, predeterminate e prescrittive** e si è tentato di **abbandonare le regole etiche, politiche od economiche**; ma dal 2003 si è tornati alla mediazione in seguito alle mancate risposte della giustizia, soprattutto in materia di **conflitto sociale**.

I giudici hanno abbandonato dunque le norme generali per tornare a quelle del caso concreto⁴⁰.

Nel 2010 possiamo riscontrare sostanzialmente due categorie di mediazione, la **Community mediation** (*Ren Min Tiao Jie*), che è parte del sistema di risoluzione alternativa delle controversie, e la **Court-performed mediation** (*Ting Fa Chu Mian Tiao Jie*), che appartiene al sistema giudiziario.

La Community mediation è formata da **Comitati di mediazione popolare**⁴¹ (o da Comitati di residenti di quartiere) che sono stati costituiti in villaggi, cittadine, unità di lavoro e nelle organizzazioni regionali o professionali per gestire le questioni civili, e penali di lieve entità.

Ogni comitato è composto da persone della comunità che vengono considerate **giuste ed imparziali**.

Sono elette **per tre anni** e vengono stipendiate con un **modesto emolumento** dal governo sia per fornire servizi di mediazione sia per educare il pubblico circa i diritti che derivano dalla legge.

Le parti **non sostengono alcun costo** per fruire dei servizi di mediazione.

La procedura di mediazione è **flessibile**, può vedere l'impiego di uno solo mediatore o di un gruppo di mediatori.

⁴⁰ V. F. HUALING – R. CULLEN, *From mediatory to adjudicatory justice: the limits of civil justice reforms in China*, University of Hong Kong, 2007.

⁴¹ In lingua inglese detti PMC (People Mediation Committees) o PCC (People Conciliation Committees).

Il mediatore incontra le parti singolarmente o congiuntamente e le aiuta a risolvere la questione.

Si stima che questi comitati affrontino mediamente **sette milioni** di casi all'anno, con un tasso di risoluzione del 90 per cento.

La *Court-Performed mediation* prevede che il giudice a cui venga assegnata la causa conduca anche la mediazione.

A differenza della *Community mediation*, ed in relazione al fatto che il processo di mediazione è parte del processo contenzioso, le parti sostengono **un costo aggiuntivo** per la mediazione.

Il giudice ha qui **forti poteri manageriali**: può chiedere alle parti di partecipare alla mediazione in tribunale oppure può recarsi di persona nel villaggio per indagare e parlare con le parti e i testimoni.

La mediazione è di tipo **valutativo**, nel senso che il giudice mediatore può far notare alle parti i punti deboli delle loro posizioni, può utilizzare unitamente alle norme giuridiche anche i **valori culturali** in modo da facilitare la composizione, può suggerire proposte di accordo, può in ultimo sottolineare i benefici economici o sociali che derivano da un accordo.

Una volta **raggiunta** la conciliazione, il giudice redige un resoconto della mediazione in cui evidenzia le pretese, i fatti, e le convenzioni. Il documento è quindi firmato da tutte le parti e ha l'effetto di una sentenza del tribunale⁴².

Anche se la mediazione è considerata **procedura volontaria**, qualcuno ha notato che questo modo di procedere potrebbe risultare coercitivo: insomma i giuristi cinesi sottolineano le stesse problematiche che aveva già il nostro conciliatore del 1865.

L'impostazione cinese attuale, dobbiamo aggiungere, non è poi così lontana dalla *judicial mediation* statunitense. E comunque l'esito, la conciliazione, si ritrova identica anche nel nostro ordinamento a partire dal decreto legislativo istitutivo della mediazione civile e commerciale.

Anche in **India** la mediazione ha un largo spazio da secoli.

⁴² L. MEALEY-LOHMANN, *Using mediation to resolve disputes*, op. cit.

Prima del **dominio coloniale** esisteva un sistema (*pañcâyat*) per il cui ripristino lottò anche lo stesso Ghandi.

La disputa tra due individui veniva rimessa ad un **collegio di saggi** che proponeva la soluzione del conflitto in base agli interessi dei due litiganti e della stessa comunità e solo se i due soggetti la rifiutavano assumevano **una decisione vincolante**.

Quindi il meccanismo era molto simile a quello antico cinese e giapponese.

In oggi la *pañcâyat* è più che altro un **organo giurisdizionale**.

Ha invece connotazioni più conciliative la cosiddetta “**corte del popolo**” (*lok adâlat*) che è formata da giuristi che ricercano l'accordo tra le parti **in modo informale** e secondo principi giuridici assai semplificati; la partecipazione alla procedura è assolutamente volontaria; vi è una decisione della corte solo se le parti **si accordano** e tale decisione non è appellabile⁴³.

Sin dai tempi antichi anche in Occidente la conciliazione, la mediazione e l'arbitrato sono stati “preferiti” al processo e quindi sono stati considerati, talvolta in modo atecnico, “**condizioni di procedibilità**”.

In alcuni contesti sociali ed economici quelli che noi definiamo strumenti alternativi non furono addirittura percepiti come tali, ma vennero considerati come mezzi di risoluzione **esclusiva** di diritto o di fatto, dei rapporti familiari, delle vicende societarie, di quelle lavoristiche e delle controversie agrarie.

Quindi siamo originariamente in sintonia con il sentire orientale.

Ciò è accaduto da quando si può parlare di Storia anche nel campo delle relazioni internazionali, specie con riguardo alla **prevenzione dei conflitti armati**: pensiamo all'opera degli Araldi in Grecia, dei Feciali a Roma, degli Irenofilaci in Magna Grecia, figure sacre queste che dovevano tentare la conciliazione a nome del loro popolo prima che venisse dichiarata la guerra.

Nella **mediazione internazionale** dell'Ottocento il ruolo del **mediatore** fu semplicemente affidato ai sovrani; all'epoca peraltro erano ben vivi tutti i principi che ispirano oggi la mediazione civile e commerciale.

⁴³ G. V. amplius F. COLOMBO, *La conciliazione in India: profili storici e prospettive attuali*, in *Ervan – Rivista Internazionale di studi afroasiatici* n. 3 – gennaio 2006.

Nel **processo ateniese classico** con riferimento a diversi reati - tra cui quello di **furto** - era già previsto un **tentativo di conciliazione obbligatorio**.

L'ordinamento processuale della *polis* greca era uno dei tanti ordinamenti presenti sul territorio. E gli altri ordinamenti, quelli della **fratria** e della **famiglia** la facevano da padrone ed avevano proprie **regole di componimento**: lo stesso Platone ne "Le Leggi" ci indica queste regole **nella conciliazione e nell'arbitrato**.

Nessuno meglio degli amici e dei parenti poteva regolare le controversie. E ciò anche perché nell'Atene classica nemmeno **il processo per questioni minori era attivabile da tutti**.

Il solo **cittadino** poteva promuovere azione presso i **Quaranta**⁴⁴, il **meteco** (lo straniero che non poteva possedere beni immobili) poteva rivolgersi solo all'Arconte **Polemarco**, i commercianti potevano investire delle loro questioni solo i **Tesmoteti**; ciò determinava una forte limitazione della **capacità processuale**.

I metodi alternativi erano invece **a disposizione di tutti** e non vedevano limitazione di sorta. Si tenga conto inoltre del fatto che la sentenza del tribunale ordinario, ossia quello elastico, era **definitiva**: e quindi chi vi ricorreva doveva aver imboccato prima altre strade che si erano rivelate insoddisfacenti.

Le occasioni **di litigio e dunque di componimento** erano molto frequenti in Grecia: non esisteva, infatti, un diritto di proprietà che un soggetto potesse vantare *erga omnes*; le stesse servitù in realtà erano solo **regolamenti convenzionali di una limitazione legale** del fondo; se ancora un soggetto **dava a pegno un bene** e non lo riscattava, almeno nei primordi, non poteva recuperare **la differenza** tra quello che avrebbe dovuto pagare ed il valore di mercato della cosa pignorata (ciò perché il creditore non poteva vendere il bene e soddisfarsi); almeno nei tempi più risalenti poi non si poteva nemmeno assegnare ad un bene mobile, benché capiente per valore, **il soddisfacimento di più crediti**.

Possiamo aggiungere che lo stesso **meccanismo processuale** sorge in origine in quanto "tollerato" dai sistemi di composizione familiari o della fratria.

Ed era peraltro un meccanismo processuale assai differente da quello che conosciamo noi a partire dalle codificazioni del XIX secolo.

⁴⁴ La magistratura minore che giudicava sino a dieci dracme.

Se affrontiamo la questione sul piano storico possiamo affermare senza tema di smentita che nella Grecia antica i giuristi non esistevano, così come non esisteva la giurisprudenza; le contese venivano composte con l'utilizzo da parte dei contendenti che se lo potevano permettere di logografi giudiziari che erano retori e dovevano essenzialmente conquistare la fiducia e la simpatia dei giudici⁴⁵; il magistrato che istruiva il processo non era un giurista, ed infine la stessa giuria che emetteva il verdetto era formata da semplici cittadini⁴⁶.

Ai magistrati ateniesi si richiedevano⁴⁷, in definitiva, il superamento dei trenta anni e la probità della famiglia, della vita e dei costumi: il senato verificava che venerassero i patri numi⁴⁸, fossero pietosi verso i genitori, avessero fatto il servizio militare, non avessero debiti con l'erario, avessero reso il conto di un'altra eventuale magistratura, non fossero falliti, non avessero patito sodomia e non avessero gettato via lo scudo in battaglia⁴⁹.

Non stupisce dunque che un frammento delle Tavole di Zaleuco⁵⁰ (VII sec. a. C.) in Magna Grecia avesse il seguente tenore: *"Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione"*⁵¹.

Nel mondo romano grande rilievo hanno senza dubbio i giureconsulti e la giurisprudenza⁵² e la preparazione giuridica per un soggetto che assiste le parti è stata da

⁴⁵ La base giuridica della disputa passa in secondo piano non essendoci meccanismi atti a valutarla. V. C. BEARZOT, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike Rivista storica del diritto greco ellenistico*, 9, 2006, p. 132. Solo eccezionalmente poteva esserci una seconda arringa tenuta da una sorta di avvocato detto *sinègore*, che di solito era un politico in vista di Atene; questi non era cioè un avvocato di mestiere e non veniva retribuito. V. R. FLACELIERE, *La Grecia al tempo di Pericle*, Rizzoli, 1983, p. 278 e 288.

⁴⁶ V. amplius E. CANTARELLA, *Diritto greco*, cit. pp. 14-16.

⁴⁷ E subivano su questo un rigido esame denominato *docimasia* da parte del Bulé o Consiglio dei Cinquecento. Col che vogliamo sottintendere che anche chi vuole esercitare come terzo la nobile arte della negoziazione deve essere sottoposto ad un esame assai rigoroso, non però principalmente od addirittura esclusivamente incentrato sulle conoscenze giuridiche.

⁴⁸ Questo peraltro è un requisito che si resisterà per l'accesso alle professioni liberali sino all'ultima guerra.

⁴⁹ C. CANTÙ, *Appendice alla Storia Universale*, vol. Unico *Delle Legislazioni*, Pomba & C., Torino, 1839, p. 94 e 95. La base della formazione oplitica comportava che se si abbandonava lo scudo si lasciava senza difesa anche "il vicino di sinistra"; il dovere e l'onore del cittadino-combattente era dunque quello di mantenere il proprio posto nella schiera assicurandone la integrità e la resistenza contro l'impeto nemico. V. F. CANTARELLA op. cit., p. 364-365.

⁵⁰ Primo legislatore dell'Occidente.

⁵¹ M. DE LUCA PICIONE, *Cenni storici sulle ADR*, in *Temì Romana*, Speciale media conciliazione, gennaio-dicembre 2010.

⁵² Perlomeno dal sorgere della letteratura giuridica ovvero nel periodo che va dalla tarda repubblica di Publio Muzio Scevola ad Ulpiano con cui il giureconsulto è ormai un pubblico funzionario e la giurisprudenza è ormai cristallizzata nella *constitutiones* imperiali. Si noti però che il ceto professionale dei giuristi nasce dalla sovversione della tradizione. Cicerone (*Delle leggi*, 2, 29,47) ci racconta che Quinto Mucio,

un certo punto in poi essenziale⁵³, ma i giudici non erano necessariamente giureconsulti. Non lo erano i Pretori dell'età repubblicana, anche se si servivano di assessori legali; non lo erano gli Imperatori che pur avevano un *consistorium auditorium*, né i Presidi o i Prefetti del pretorio che a loro volta erano coadiuvati dagli Assessori e così pure i Difensori di città⁵⁴ dell'epoca imperiale, e per venire a tempi successivi non lo erano gli Sculdasci dei Longobardi, il Baiulo degli Svevi o i Consoli di giustizia dell'età delle repubbliche⁵⁵, il giudice di pace inglese⁵⁶, il giudice di pace francese del 1790⁵⁷, il conciliatore della Repubblica Ligure del 1798, il conciliatore italiano del 1865, i conciliatori francesi introdotti nel 1978.

Sino all'Età dei lumi possiamo dire che **la giustizia non era dunque amministrata da giuristi professionali** e gli stessi giuristi per il Giudice erano di consultazione facoltativa. Napoleone ai primi dell'Ottocento fu tra i primi ad obbligare i giuristi a **frequentare le scuole di legge**.

Di contro già nella Roma repubblicana quelli che Cicerone chiamava *disceptatores domestici* conciliavano dalle sei del mattino alle sei di sera e la conciliazione **era così diffusa** che addirittura venne vietata da **Caligola** che temeva venissero messe a repentaglio le entrate imperiali: aveva infatti messo una imposta del **40% sulle entrate giudiziarie**.

L'uso della conciliazione a Roma ci è attestato anche **dall'Evangelista Luca** (12, 58-59): *“Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei*

figlio di Publio, afferma di aver udito il padre che non può essere buon pontefice colui che non abbia conoscenza dello *ius civile* (ossia delle giurisprudenza e della prassi giudiziaria). Sino ad allora era la pratica pontificale che fondava lo *ius civile* e non viceversa (v. *amplius* A. SCHIAVONE, *Il giurista*, in *L'uomo romano* a cura di Andrea Giardina, Laterza, 2001, p. 92 e ss.).

⁵³ V. *amplius* U.E. PAOLI, *Vita romana*, Le Monnier, Firenze, 1962, p. 168 e ss.

⁵⁴ L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, in *Digesto Italiano*, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, p. 44.

⁵⁵ Eccezione al principio sono forse lo Scabino di età franca che potremmo definire erede del giureconsulto romano ed il Bailo, giudice e conciliatore nelle terre non feudali che doveva essere notaio. Solo nel 1770 in Piemonte si iniziò a richiedere la laurea per i giudici di nomina regia. (Cfr. Atti parlamentari subalpini, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1869, p. 360) anche se, per la verità già una norma savoiarda del 1430 (*Statuta Sabaudiae*; v. in seguito Leggi e Costituzioni di Sua Maestà del 1729 art. 2 lib. II Tit. V) richiedeva ai giudici di città e delle terre non feudali di essere dottori.

⁵⁶ Per questa carica i professionisti del foro venivano deliberatamente esclusi. Ma con una legge del 25 maggio 1871 si limitò l'incompatibilità all'*attorney* o *solicitor* (procuratore e avvocato) che eserciti la professione nella stessa contea. L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, p. 48. Il giudice di pace in un primo tempo era comunque assistito da due giuristi chiamati *Quorum*.

⁵⁷ Che era parimenti affiancato da due assessori.

debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato l'ultimo spicciolo."

Un tentativo obbligatorio duplice, preventivo e diremmo noi, processuale, era previsto poi proprio su ispirazione del principio evangelico testé citato, davanti **al tribunale del vescovo** (udienza episcopale); il tentativo preventivo di conciliazione si teneva il **lunedì** per dar modo al vescovo di condurre, se fosse fallito, **un altro tentativo** di conciliazione da solennizzare nel corso della **liturgia domenicale**⁵⁸.

Le Arti manifatturiere in **Veneto** nel XIV secolo regolavano tutte le controversie tra gli iscritti tramite una magistratura di conciliazione che aveva anche il compito di apprestare **mutui soccorsi e di costruire chiese**⁵⁹.

Tale sistema di composizione diventa centrale anche **in Francia** nel XVI secolo tanto che **viene regolato** dalla legge: a quel tempo i commercianti incontravano dei problemi nell'adire i Tribunali di commercio perché **i giudici non avevano le necessarie competenze tecniche** per gestire le loro controversie e non era ammessa la **testimonianza orale**; quindi i mercanti non potevano chiamare a testimoniare **gli esperti** di una data materia.

Con una legge del 1563 dunque si consentì ai Tribunali di commercio francese di nominare un **esperto** (arbitro-relatore)⁶⁰ che sentiva le parti, provava a conciliarle e se non ci riusciva ne riferiva al Tribunale.

L'arbitro-relatore diverrà poi nel *Code commerciale* del 1806 **l'arbitro-conciliatore** e di legislazione in legislazione facilmente arriverà alla nostra del '42 con **l'esame contabile** (art. 198-200 C.p.c.), per approdare poi tra i sistemi ADR americani con il nome di *neutral early evaluator*, ruolo da ultimo legittimato dall'*Administrative Dispute Resolution Act* nel 1998.

⁵⁸ V. amplius T. INDELLI, *La episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Valentiniano III (sec. IV-V d. C.)*, in http://www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=85

⁵⁹ C. CANTÙ, *Storia degli Italiani*, tomo IV, Cugini Pomba e Comp. Editori, 1853, p. 632.

⁶⁰ Cfr. il sito degli attuali eredi in Francia di quegli antichi mediatori valutativi in <http://www.mediation-ieam.com/Historique.asp>

Nello Stato sabaudo settecentesco ritroviamo una norma risalente a Federico II di Svevia⁶¹, per cui si affidava la risoluzione delle controversie **tra le genti rustiche** a mezzi alternativi obbligatori e non è certo un caso isolato.

Così si esprimono gli Statuti di Sua Maestà (1729-1770): *“Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione de’ confini, o altro incommodo che si pretendesse ne’ beni, e percezione dei loro frutti, **chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre**, che sieno uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto”*.

Sempre nel **XVIII secolo**, il tentativo preventivo di conciliazione è stato sicuramente **obbligatorio** nei Paesi Bassi, nel Cantone di Ginevra (1713-1816), ed in Prussia (1745).

E questo stato di cose si è protratto anche successivamente alla Rivoluzione francese quando la tendenza, di costume o di necessità, a praticare uno strumento extraprocessuale **divenne un testo giuridico** che si affermò tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento in tutta Europa.

Rammento appunto il caso della Francia (1790), della Danimarca (1795), della Repubblica Cisalpina (1797), della Repubblica Ligure (1798-1805), della Repubblica Romana (1798-99) della Liguria annessa alla Francia (1805-1814), della Norvegia (1800), della Spagna (1812, 1821 e 1856), dell’Austria e domini (Lombardia e Venezia) 1815, dell’Impero ottomano (con riferimento alle relazioni consolari dei sudditi austriaci) (1855), dei Codici di commercio Ungherese e Portoghese (1800-1850), del Codice di procedura civile estense del 1852.

Il tentativo di conciliazione preventivo⁶² diventa facoltativo per le parti (ma non per il giudice) in reazione a Napoleone solo **nel Regno delle Due Sicilie a partire dal 1819**, ma si deve tener conto che comunque all’epoca in diverse materie vi era l’arbitrato obbligatorio che terrà in Italia sino al 1982 quando si sostituirà con il **tentativo obbligatorio di conciliazione agraria**.

In ogni caso anche nel Sud qualora a litigare fossero delle **Pubbliche Amministrazioni** il tentativo di conciliazione **restava obbligatorio**.

⁶¹ Che a sua volta si era rifatto alle XII Tavole della Roma arcaica.

⁶² Salvo il caso degli Stati Sardi che hanno sempre rifiutato l’obbligatorietà di un tentativo preventivo, ma avevano comunque un tentativo giudiziale obbligatorio per il giudice,

Costante dunque nei secoli è la fuga dal **formalismo processuale** ed il rispetto del controllo privato delle forme della contesa. In Lombardia sino alla Rivoluzione del '48 erano le parti a scegliere il rito più appropriato (tra quello verbale e quello scritto) e non il giudice.

Dopo il 1860 in Italia la conciliazione come **condizione di procedibilità** la ritroviamo nel **Codice della Marina Mercantile** del 1865, nella legge istitutiva dei **probiviri** (1895), nella legge del **1926** istituyente l'ordinamento corporativo, nel codice di rito del '42 dove era addirittura **condizione di proponibilità della domanda** in ordine alle controversie **collettive**.

Venuto meno l'ordinamento corporativo il tentativo di conciliazione obbligatorio preventivo davanti alle associazioni sindacali "sostituisce" **come condizione di procedibilità** del successivo giudizio, **l'obbligo di denuncia** all'associazione sindacale previsto nel periodo fascista per il tentativo individuale.

A seguito degli strali della Corte costituzionale nei confronti dei contratti collettivi di lavoro *erga omnes*, che contenevano anche clausole di conciliazione obbligatoria, rimane in piedi **il regime della facoltatività**.

Ma già nel 1973 e poi nel 1990 riprende **il viatico del tentativo obbligatorio** in relazione all'impugnazione del licenziamento.

Dal 1998 abbiamo ancora per tutta la materia del lavoro un doppio tentativo obbligatorio, **giudiziale e stragiudiziale** a cui si aggiunge del 2004 l'obbligatorietà del tentativo davanti alle Commissioni di certificazione nel caso in cui si voglia impugnare **un contratto certificato**.

Solo a partire dal 5 novembre 2010 si è tornati ad un tentativo extragiudiziale di conciliazione **facoltativa** nella materia del lavoro, ferma sempre l'obbligatorietà del predetto tentativo davanti alla **Commissioni di certificazione**.

Si annota però qui che la recente riforma del mercato del lavoro che dovrebbe approdare a breve in gazzetta ufficiale ci fa tornare alla **obbligatorietà** del tentativo di conciliazione: si

prevede, infatti, una particolare procedura nel caso di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo**⁶³.

Da **1995 al 2006** poi il tentativo di conciliazione giudiziale **si è mantenuto obbligatorio** anche per il processo civile ordinario.

Troviamo ancora il tentativo di conciliazione come **condizione di procedibilità** in materia di pubblici servizi, di telecomunicazioni, di sub-fornitura, di pubblico impiego⁶⁴ e di diritto di autore.

Emerge alla luce degli esempi tratteggiati che in passato le controversie si risolvevano o con una conciliazione perlomeno “sentita” come obbligatoria, quando non disposta dalla legge, come condizione di procedibilità.

Quanto alle caratteristiche della conciliazione si può dire che in Italia ed in Europa è prevalso il modello **valutativo del conciliatore consigliere delle parti**.

L'UNCITRAL⁶⁵ negli anni '80 ha fatto tuttavia toccare con mano che perlomeno con riferimento al commercio internazionale le buone prassi dei Paesi ONU individuavano un **modello facilitativo** nel quale, in altre parole, il mediatore manteneva il ruolo di mero facilitatore della comunicazione tra le parti.

Di qui la riflessione ha toccato l'Europa che prima con una raccomandazione del 2001⁶⁶ e poi col Libro Verde nel 2003 ha tracciato la strada **in senso facilitativo**.

Il novello mediatore civile e commerciale italiano è invece un soggetto che in prima battuta fa della facilitazione, ma in seconda può anche emettere **una proposta**.

La legge stabilisce semplicemente che “*Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia*”⁶⁷, ma non specifica il “come” della sua azione e l'art. 2 del decreto legislativo 28/10 ci conferma che per mediazione civile e commerciale si fa riferimento ad una procedura “*svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad*

⁶³ Si fa riferimento qui a quello che potrebbe essere a breve il nuovo testo articolo 7 della legge 15/07/1966, n. 604 come introdotto dall'art. 1 c. 40 del disegno di legge definitivamente approvato n. 5256/12 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

⁶⁴ Sino al 5 novembre 2010.

⁶⁵ Si tratta dell'Organo che si occupa del commercio internazionale in sede alle Nazioni Unite.

⁶⁶ Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1016] gazzetta ufficiale n. L 109 del 19/04/2001 pag. 0056 - 0061.

⁶⁷ Art. 8 c. 3 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;"⁶⁸ e dunque il nostro ordinamento consente una procedura flessibile.

La procedura di mediazione peraltro può comporsi di **sessioni congiunte e riservate**⁶⁹: questa impostazione peraltro era già propria della conciliazione del 1865 e verrà ripresa in proprio in quegli anni anche nel processo di **separazione dei coniugi** per arrivare sino ai giorni nostri.

La mediazione attuale funziona come **condizione di procedibilità** per tutta una serie di materie⁷⁰ che costituiscono la **maggioranza** delle controversie: dopo una parentesi di conciliazione generale volontaria durata più o meno **duecento anni** si è dunque tornati alla **conciliazione obbligatoria**.

Arlene McCarthy, relatrice della direttiva 52/08 che è stata recepita in Italia appunto con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ha da ultimo precisato⁷¹ che lo strumento obbligatorio **rende effettiva l'attuazione della direttiva stessa** e che dunque il nostro paese sta camminando sulla **buona strada**; tale giudizio non può lasciare indifferente la Corte Costituzionale che nel prossimo autunno dovrebbe stabilire se una mediazione obbligatoria sia **compatibile o meno** col dettato costituzionale.

Se l'approccio alla mediazione è comunque almeno in prima battuta quello **facilitativo** *conditio sine qua non* è che la procedura sia affidata ad un soggetto in grado di conoscere elementi di **comunicazione**, **negoziazione** e di **psicologia**, seppure la conoscenza di questi ultimi ed in particolare delle dinamiche conflittuali, **non comporti ovviamente attività terapeutica**⁷².

⁶⁸ Art. 2 c. 1 lett. a) decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

⁶⁹ Art. 9 c. 2 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

⁷⁰ Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

⁷¹ A. MCCARTHY "Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea" in Convegno ADR Center "Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione", Milano, 6 giugno 2012.

⁷² Nella procedura di mediazione il "terzo" è l'ago della bilancia del procedimento. Il buon esito del procedimento dipende in larga parte dalla sua abilità di condurre le trattative tra le parti. Un'abilità che presuppone non solo competenze giuridiche, ma anche tecniche di comunicazione, che non possono essere improvvisate (così si esprime A. MASUCCI, LA "MEDIAZIONE" IN FRANCIA, GERMANIA E NEL REGNO UNITO. *Un valido rimedio alternativo alla sentenza nelle liti con la pubblica amministrazione?*, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2008, 6, 1353.); il mediatore è un professionista qualificato, esperto di tecniche di *conflict*

Il mediatore deve essere dunque **un soggetto istruito**⁷³, ossia un soggetto che possiede **conoscenze di tipo teorico**, relative al background personale e professionale (sapere = contenuti e fondamenti scientifici), **abilità di gestione**⁷⁴ e di **analisi**⁷⁵ (saper fare = tecniche, procedure e abilità), **capacità comunicative e relazionali**⁷⁶ (saper essere = atteggiamenti e comportamenti), **ductilità**⁷⁷ (saper divenire⁷⁸) ed infine avere delle spiccate **attitudini personali**⁷⁹.

In **estrema sintesi** secondo le conclusioni di un lavoro legato ad uno studio americano, sarebbero **sei** le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono un buon mediatore: capacità di indagine⁸⁰, dimostrazione di empatia⁸¹, capacità di inventiva⁸², capacità di persuasione⁸³ e distrazione⁸⁴, conoscenza della materia su cui verte la disputa⁸⁵.

resolution e conoscitore delle dinamiche conflittuali soprattutto dal punto di vista psicologico, competente a conoscere i risvolti giuridici delle singole controversie, si tratta generalmente di psicologi, talvolta di giuristi appositamente "formati" (v. G. COSI, *Perché conciliare? cit.*); gli strumenti utilizzati dal mediatore sono tratti soltanto in minima parte dalla formazione professionale (giuridica o economica o in generale tecnica in cui affonda la controversia): per riuscire a far conciliare le parti in lite, infatti, rilievo prevalente hanno altre doti e qualità, legate alla psicologia, alle tecniche di comunicazione di persuasione... (G. FINOCCHIARO, *Mediazione le novità*, in Guida al Diritto, n. 12 del 20 marzo 2010.).

⁷³ "Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato". Art. 1 codice deontologico UNIONCAMERE.

⁷⁴ Conservare l'imparzialità; gestire le interazioni negative; saper formulare le domande per fare emergere le vere motivazioni; aiutare le parti a generare le opzioni creative; aiutare le persone ad identificare i principi e criteri necessari per facilitare la loro presa di decisione; aiutare le parti a valutare se la decisione presa è fattibile.

⁷⁵ Lavorare con le risposte date dalle parti; analizzare conflitti di qualsiasi complessità e dimensione; individuare e analizzare le dinamiche di interazione tra i partecipanti.

⁷⁶ Comunicazione verbale, non verbale e paraverbale coerenti; empatia, capacità di riconoscere emozioni proprie e degli altri, ascolto attivo, assertività, atteggiamento non difensivo.

⁷⁷ Capacità di trasformarsi, di mettersi in gioco, di saper orientarsi e riorientarsi continuamente.

⁷⁸ Anche capacità di auto-formarsi e formazione continua.

⁷⁹ Flessibilità ("Perciò come l'acqua modella il suo corso secondo la natura del terreno su cui scorre così il generale trova la vittoria in relazione al nemico che ha di fronte"; "Colui che può modificare le proprie tattiche in relazione al nemico e, pertanto, ottenere la vittoria può essere definito un condottiero divino". Sun Tzu, *Bingfa*, V, 32-33), creatività, autocontrollo, capacità di superare i pregiudizi personali, dinamismo, empatia.

⁸⁰ Nel 2009 lo stesso autore precisa che dal 1995 (Cfr. C. HONEYMAN, *Performance-based Testing the mediators (a lightning speed-tours)*, Convenor conflict management, september 2009) il termine "investigation" è stato sostituito con "gathering information" ossia con raccolta di informazioni.

⁸¹ Il termine "empathy" è stato separato sempre nel 1995 da "impartiality" (Cfr. C. HONEYMAN, *Performance-based Testing cit.*).

⁸² Il termine "inventiveness" è stato ridefinito con il termine "generating options", ossia con "generazione di opzioni" (Cfr. C. HONEYMAN, *Performance-based Testing cit.*).

⁸³ Si parla oggi di "generating agreements", ossia di generazione di accordi. (Cfr. C. HONEYMAN, *Performance-based Testing cit.*)

Non appare per nulla semplice rinvenire così tante caratteristiche in **una persona sola**, e del resto nell'operare del mediatore non potrebbe, secondo gli esperti, esserci alcuna **lacuna** in merito, qualora si voglia condurre una mediazione **in modo efficace**: il ruolo del mediatore non è dunque, come si vorrebbe credere, alla "portata" di tutti.

E se non ci sono **abilità innate** su cui lavorare, a maggior ragione si può sostenere che è necessaria una formazione che **valorizzi** al meglio il cammino.

La formazione è forse il nodo più spinoso che i governi dei singoli stati si trovano a sciogliere e spesso debbo dire che **resta irrisolto**.

I programmi dei **corsi di aggiornamento** che in Italia si aggiungono alla formazione di base vengono sostanzialmente approvati dal Ministero quando contemplan la trattazione delle **materie giuridiche** che costituiscono condizione di procedibilità.

Il che non pare di grande ausilio alla **necessaria crescita** del professionista nella conoscenza delle **dinamiche del conflitto** ed in particolare degli strumenti deputati al **disinnesco** degli elementi **oggettivi** (filtri sessuali, neurologici, sociali, percezioni selettive, relazioni interpersonali implicite, malintesi ecc.) che hanno portato all'instaurarsi della controversia e che sono di **assoluto intoppo** alla comunicazione.

Ci sono in altre parole conoscenze **non giuridiche** che stanno alla base di ogni intervento del mediatore che **non possono essere tralasciate o sacrificate**.

L'esperienza insegna che se la formazione impartita a un mediatore non riesce ad aiutarlo a passare oltre la prima ondata di **entusiasmo** con un vero senso del **proprio potenziale**, ripetuti rapporti con parti recalcitranti possono causare tensione e frustrazione. Questo è particolarmente **vero** nei casi in cui le parti tendono a credere che se non mediano hanno poco da perdere⁸⁴.

Per superare gli impacci è a giudizio dello scrivente in primo luogo necessario che il mediatore effettui **un lavoro continuo** su se stesso al fine di formulare al meglio le

⁸⁴ Alcuni mediatori quando la trattativa sembra non avere sbocchi ritengono di "distrarre" i contendenti con battute e barzellette. Questa caratteristica in Wisconsin si fa rientrare nella più generale gestione delle interazioni (*managing the interaction*). (Cfr. C. HONEYMAN, Performance-based Testing cit.)

⁸⁵ Investigation, demonstrations of empathy, invention, persuasion and distraction, knowledge of the field in which the dispute takes place. Cfr. C. HONEYMAN, *Five Elements of Mediation*, Negotiation Journal, April 1988. In <http://www.convenor.com/madison/five.htm>

⁸⁶ C. HONEYMAN, *Five Elements of Mediation*, cit.

domande appropriate alla continuazione della trattativa, può di certo aiutarlo in ciò una buona conoscenza di quanto ci offre oggi l'**analisi transazionale**.

Le **transazioni parallele**, dove sono interessati gli stessi **stati dell'Io** dei due interlocutori, rappresentano, infatti, le situazioni **più facili**, poiché nella transazione, nello scambio comunicazionale, viene usato **lo stesso codice** e viene messo in gioco il **medesimo sistema di valori**; e dunque in tali condizioni la comunicazione potrebbe continuare all'infinito.

L'analisi transazionale può aiutare peraltro il mediatore a mantenere l'autorevolezza senza farlo scivolare nell'autoritarietà che nell'esperienza appare come una delle **minacce più gravi** alla facilitazione.

Ma al fine della **formulazione delle domande** può essere allo stesso tempo davvero illuminante la conoscenza delle tipologie psicologiche che ci vengono offerte **dall'enneagramma** o più in generale lo studio che ci offre la psicologia delle **motivazioni psicologiche dominanti** (bisogno di affiliazione, bisogno di successo e bisogno del potere) e **dell'ordine** in cui si devono prendere in esame in riferimento al soddisfacimento.

Ci sono in altre parole tipologie di persone a cui ad esempio la proposizione di **domande ipotetiche** può rivelarsi **poco utile se non dannosa** (ad es. per il tipo 3 detto "manager") ed è importante dopo averla individuata, saper puntare, qualora si debba scegliere, sulla coltivazione dell'esigenza **più importante** e/o **più motivante** (ad es. si è scoperto che nel rapporto di lavoro l'aumento dello stipendio non è motivante, mentre è motivante il lavoro di per sé) ovvero sui bisogni che sono **funzionali** ad altri piuttosto che su quelli che sono **disfunzionali**.

Chi scrive ritiene ancora che un **efficace sviluppo** delle tecniche per favorire **la creatività** debba partire almeno da un'infarinatura di neurofisiologia, circa il funzionamento dei neuroni (le reazioni elettro-chimiche, il ruolo delle sinapsi e dello spazio intersinaptico, le partizioni del sistema nervoso, il cervello tripartito e le reti neurali ecc.), dallo studio della asimmetria degli emisferi e della tipologia delle onde cerebrali; o ancora che si possa accedere nel modo più consapevole al significato del linguaggio del corpo solo nel caso in cui il mediatore conosca in modo adeguato i fondamenti della **psicologia analogica**.

La conoscenza del linguaggio del corpo può rivelarsi **vincente** per individuare ad esempio quali siano gli argomenti di reale interesse per il mediatore, per comprendere quando sia il caso di **cambiare** discorso o di **alleggerirlo**.

L'empatia è il **sale della mediazione**: ebbene ci si può fare un'idea più precisa a partire dall'approfondimento della sterminata letteratura sui **neuroni specchio**.

Il mediatore opera in una situazione dove dominano **potenti** lo stress e le emozioni negative, specie la **rabbia e la paura**: importante è dunque studiare il **percorso** e la **valutazione** delle emozioni a partire e delle strutture in cui si articola il **cervello sociale** (amigdala, corteccia cingolata, corteccia prefrontale orbitomediale ecc.), anche perché ciò permette di "subodorare" una patologia e dunque di interrompere la procedura di mediazione.

Risulta vitale per preservare l'imparzialità ed alimentare l'assertività la conoscenza dei meccanismi difensivi che ciascuno di noi pone in atto e che ci vengono illustrati così eloquentemente dalla **psicologia dinamica**; non si può ignorare che gli **schemi emozionali** *"si formano sulla base di interazioni ripetute con la madre (con l'accudente), sin dall'inizio della vita"*⁸⁷ e dunque non tralasciare il ruolo primario dell'evoluzione psichica infantile in merito all'apprendimento e più in generale all'associazione di comportamenti, sensazioni ed emozioni.

Non bisogna dimenticare che il mediatore ha comunque a che fare con delle **persone**.

Se si parte da questo presupposto non appare dunque un caso che ad esempio la conciliazione e la **psicologia dinamica** si fondino su postulati di base simili⁸⁸ seppure le due discipline abbiano **finalità diversissime**.

⁸⁷ W. BUCCI, *Lo spettro dei processi dissociativi. Implicazioni per la relazione terapeutica*, in *Psicoanalisi e neuroscienze Risonanze interdisciplinari* a cura di Giuseppe Moccia e Luigi Solano, FrancoAngeli, 2009, p. 30.

⁸⁸ *"La psicoanalisi ha immesso nella cultura scientifica (ma non solo scientifica) del secolo (appena) trascorso un'enorme mole di ipotesi di lavoro che sono andate al di là della psicoanalisi stessa e che sono divenute in tempo breve programmi di ricerca adottati e portati avanti da tante altre discipline". A. FALCI, 3. Der geist in the machine. I presupposti della ricerca psicoanalitica e i confronti con la teoria del codice multiplo, in Psicoanalisi e neuroscienze Risonanze interdisciplinari a cura di Giuseppe Moccia e Luigi Solano, FrancoAngeli, 2009, p. 91. "Grazie alle idee che si sono venute sviluppando negli ultimi decenni noi abbiamo oggi gli strumenti per prendere le distanze dal riduzionismo e dal dogmatismo teorico. Questo è sicuramente un gran bene, almeno per chi parteggia per un'idea laica della psicoanalisi, aperta al confronto con le altre discipline della contemporaneità: con la psichiatria e con altri orientamenti psicoterapeutici e anche con la filosofia e le neuroscienze". G. MARTINI, 1. Nuove prospettive sul funzionamento mentale inconscio e loro riflessi nella pratica clinica, in Psicoanalisi e neuroscienze Risonanze interdisciplinari a cura di Giuseppe Moccia e Luigi Solano, FrancoAngeli, 2009, p. 99.*

Intendiamoci il mediatore **non fa, né può fare** in mediazione **lo psicoterapeuta**, anche nel caso in cui ne avesse per avventura la qualifica, perché si occupa solo di **un rapporto controverso**, così come del resto il mediatore-avvocato non può fare in mediazione l'avvocato, ma è un **dato di fatto** che alla base della mediazione e della psicologia dinamica si ritrovino diversi **elementi condivisi** che andrebbero dunque approfonditi nella loro *ratio*.

Ciò vale, come già indicavo⁸⁹, per la **plasticità** e la **flessibilità** e dunque **l'assenza di protocolli standardizzati**, l'evitamento delle forzature, la neutralità dell'operatore, l'aiuto altrui, lo studio della mimica, del comportamento e del modo di parlare, lo scambio delle parole, la segretezza e confidenzialità, un **particolare legame emotivo** tra operatore e soggetto, il poter comunicare quello che viene in mente **senza la paura di ricevere una critica**, una mente libera da preventive consapevolezze, lo studio della **propria personalità**, la consapevolezza della mancanza di identità tra **conscio e psichico**, lo studio di elementi **apparentemente insignificanti e mancanti**, il fatto che siano **i portatori del conflitto a porgere la soluzione**, il fatto che si consideri sempre incerto l'esito della cura/procedura, effetti dipendenti dall'umanità dell'operatore (capacità relazionale, sensibilità, intuizione, empatia, esperienza), **l'indeterminatezza del fattore tempo**, la **calibratura** delle distanze, il "cambio" dei ricordi, la consapevolezza che gli **interventi verbali** possano essere un veicolo di comunicazione **non ottimale**⁹⁰.

Ciò che qui sostengo in tema di incremento delle conoscenze trova riscontro nella **formazione avanzata** dei mediatori in diversi paesi al mondo (Canada⁹¹, Sud Africa⁹² ecc.).

⁸⁹ V. C.A. Calcagno, *Breve nota sul rapporto tra mediazione civile e commerciale e psicoanalisi*, in www.mediaresenzaconfini.org, 25 aprile 2012.

⁹⁰ La scrivente ha un vero e proprio culto ad esempio del silenzio che osserva il più possibile all'interno delle sessioni di mediazione.

⁹¹ "ADR Canada's Competency Assessment Criteria require a candidate for C.Med certification to complete at least 80 hours of mediation theory and skills training in mediation programs approved by ADR Canada, plus at least 100 hours of study or training in dispute resolution generally, covering the psychology of dispute resolution, negotiation, public consultation, mutual gains bargaining, communication, management consulting, conflict management, or specific substantive areas such as law, psychology, social work, counselling, etc." The ADR Institute of Canada (ADRIC) IMI Q.A.P. <http://imimediation.org/qap-profile-adr-institute-of-canada>

⁹² "The Pathway to Mastery includes:... Psychology of Conflict (1-day)..." Mediation and Training Alternatives (MATA) IMI Q.A.P. in <http://imimediation.org/qap-profile-mata>.

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- C. BEARZOT, *Diritto e retorica nella polis democratica ateniese*, in *Dike Rivista storica del diritto greco ellenistico*, 9, 2006, p. 132.
- W. BUCCI, *Lo spettro dei processi dissociativi. Implicazioni per la relazione terapeutica*, in *Psicoanalisi e neuroscienze Risonanze interdisciplinari* a cura di Giuseppe Moccia e Luigi Solano, FrancoAngeli, 2009, p. 30.
- A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, UTET, Torino, 1987.
- E. CANTARELLA, *Diritto greco*, Cuem, Milano, 1994.
- C. CANTÙ, *Appendice alla Storia Universale*, vol. Unico *Delle Legislazioni*, Pomba & C., Torino, 1839, p. 94 e 95.
- C. CANTÙ, *Storia degli Italiani*, tomo IV, Cugini Pomba e Comp. Editori, 1853, p. 632.
- P. CAO, *The origins of mediation in traditional China*, in *Dispute Resolution Journal*, May 1999.
- F. COLOMBO, *La conciliazione in India: profili storici e prospettive attuali*, in *Ervan – Rivista Internazionale di studi afroasiatici* n. 3 – gennaio 2006.
- F. COSÌ, *Perché conciliare?* in dispensa Corso Base e di specializzazione per conciliatori ai sensi del d.lgs. n. 5/03, Associazione Equilibrio & Risoluzione delle controversie, 2010.
- L. COZOLINO, *Il Cervello Sociale. Neuroscienze delle relazioni umane*, Raffaello Cortina Edizioni, 2008.
- M. DE LUCA PICIONE, *Cenni storici sulle ADR*, in *Temi Romana, Speciale media conciliazione*, gennaio-dicembre 2010.
- A. FALCI, 3. *Der geist in the machine. I presupposti della ricerca psicoanalitica e i confronti con la teoria del codice multiplo*, in *Psicoanalisi e neuroscienze Risonanze interdisciplinari* a cura di Giuseppe Moccia e Luigi Solano, FrancoAngeli, 2009, p. 91.
- E. FELDMAN, *Law, Culture, and Conflict: Dispute Resolution in Postwar Japan*, 13 settembre 2007, p. 54 e ss. in *NELCO Legal Scholarship Repository*, University of Pennsylvania Law School. <http://lsr.nellco.org>
- G. FINOCCHIARO, in *Guida al Diritto*, n. 12 del 20 marzo 2010, *Il Sole-24Ore*.
- R. FLACELIERE, *La Grecia al tempo di Pericle*, Rizzoli, 1983, p. 278 e 288.
- K. FUNKEN, *Comparative Dispute Management "Court-connected Mediation in Japan and Germany"*, (March 2001). University of Queensland School of Law Working Paper No. 867. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=293495> or doi: 10.2139/ssrn.293495.
- C. HONEYMAN, *Five Elements of Mediation*, *Negotiation Journal*, April 1988. In <http://www.convenor.com/madison/five.htm>
- C. HONEYMAN, *Performance-based Testing the mediators (a lightning speed-tours)*, in *Convenor conflict management*, september 2009.
- F. HUALING – R. CULLEN, *From mediatory to adjudicatory justice: the limits of civil justice reforms in China*, University of Hong Kong, 2007.
- T. INDELLI, *La episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Valentiniano III (sec. IV-V d. C.)*, in http://www.sintesonline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=85
- G. LUCARELLI, *Manager, samurai e "l'Arte della spada". Saggezza antica per problemi moderni*. 9 Settembre 2011. In <http://www.ticonzero.info/articolo/manager-samurai-e-l-arte-della-spada-saggezza-antica-per-problemi-moderni/2081/>
- G. MARTINI, 1. *Nuove prospettive sul funzionamento mentale inconscio e loro riflessi nella pratica clinica*, in *Psicoanalisi e neuroscienze Risonanze interdisciplinari* a cura di Giuseppe Moccia e Luigi Solano, FrancoAngeli, 2009, p. 99.
- A. MASUCCI, *LA "MEDIAZIONE" IN FRANCIA, GERMANIA E NEL REGNO UNITO. Un valido rimedio alternativo alla sentenza nelle liti con la pubblica amministrazione?*, in *Riv. it. dir. pubblico comunit.* 2008, 6, 1353.
- A. MCCARTHY *"Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea"* dattiloscritto in *Convegno ADR Center "Il giusto rapporto tra giurisdizione e mediazione"*, Milano, 6 giugno 2012.
- L. MEALEY-LOHMANN, *Using mediation to resolve disputes – Differences between China and the United States*, in <http://www.chinainsight.info>, 2010.

U.E. PAOLI, *Vita romana*, Le Monnier, Firenze, 1962, p. 168 e ss.

Y. SATO, *Commercial Dispute Processing and Japan*, in New York: Kluwer Law International, 2001, p. 330.

L. SCAMUZZI, voce *Conciliatore e conciliazione giudiziaria*, in *Digesto Italiano*, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, p. 44.

T. KAWASHIMA, "*Dispute Resolution in Contemporary Japan*," in Arthur Taylor von Mehren, ed., *Law in Japan: The Legal Order in a Changing Society* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963).